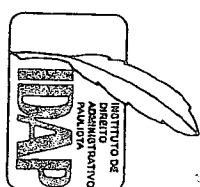




INSTITUTO GERALDO ATALIBA
IDEPE — INSTITUTO INTERNACIONAL
DE DIREITO PÚBLICO E EMPRESARIAL



ANTIGOS CONSELHEIROS

- Ataliba Nogueira • Cândido Motta Filho • Geraldo Ataliba (Fundador) • Hely Lopes Meirelles
- Joaquim Canuto Mendes de Almeida • M. Seabra Fagundes • Pontes de Miranda
- Oswaldo Aranha Bandeira de Mello • Rubens Gomes de Sousa
- Ruy Cirne Lima • Victor Nunes Leal

DIRETORES

- Celso Antônio Bandeira de Mello • Adilson Dallari

CONSELHO DE ORIENTAÇÃO

- Almir do Couto e Silva • Caio Tácito • Carlos Mário Veloso • Dalmo Dallari
- Fábio Konder Comparato • Josaphat Marinho • José Francisco Rezek • Lourival Villanova
- Michel Temer • Raul Machado Horta • Sérgio Ferraz • Vicente Marotta Rangel

COMISSÃO EDITORIAL

- Antônio Carlos Cintra do Amaral • Carlos Ayres Britto
- Carlos Ari Sundfeld • Carlos Roberto Martins Rodrigues • Carlos Roberto Pellegrino
- Diógenes Gasparini • Eros Roberto Grau • Fernando Albino de Oliveira
- Francisco Octávio de Almeida Prado • Homar Cais • José Manoel de Arruda Alvim Neto
- Lucia Valle Figueiredo • Luiz Carlos Bettiol • Luís Roberto Barroso • Maria Helena Diniz
- Maria Sylvia Zanella Di Pietro • Paulo de Barros Carvalho • Régis Fernandes de Oliveira
- Roberto Rosas • Rosolea Folgosi • Sérgio Andréa Ferreira • Sérgio Lazzarini
- Torquato Lorena Jardim • Valmir Pontes Filho

SECRETÁRIO EXECUTIVO

- Hélcio de Abreu Dallari Júnior

RTDP

Publicação trimestral de
MALHEIROS EDITORES LTDA.

Rua Paes de Araújo, 29, cj 171

CEP 04531-940 - São Paulo, SP - Brasil

Tel.: (011) 3842-9205 - FAX: (011) 3849-2495

Assinaturas e comercialização:

CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE
LIVROS S.A.

Rua Conselheiro Ramalho, 928

CEP 01325-000 - São Paulo, SP - Brasil

Tel.: (011) 289-0811 - FAX (011) 251-3756

Setor responsável: Alvaro Malheiros

L. retora: Suzana Fleury Malheiros

Supervisão Gráfica: Vania Lúcia Amato
Editoração Eletrônica: Ciga's Studio

SUMÁRIO

DOCTRINA

DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA

— José Afonso da Silva

5

ALGUNS ASPECTOS JURÍDICOS DA BIODIVERSIDADE

— Newton De Lucca

14

PROCESSO ADMINISTRATIVO: PRAZOS, PRECLUSÕES

— Sérgio Ferraz

45

DEMOCRACIA, CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

— Carmen Lúcia Antunes Rocha

60

OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL

— Adilson Abreu Dallari

68

ANAMNESE DA MEDIDA PROVISÓRIA

— Sérgio Servulo da Cunha

77

CONCEITO DE INTERESSE PÚBLICO E A "PERSONALIZAÇÃO" DO DIREITO ADMINISTRATIVO

— Marçal Justen Filho

115

REEDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA (VISÃO COMPARATIVA DAS JURISPRUDÊNCIAS DA CORTE CONSTITUCIONAL ITALIANA E DO STF)

— Edilson Pereira Nobre Junior

137

PARECERES

PORTO — ARRENDAMENTO — CESSÃO E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO

— Tércio Samirio Ferraz Junior

144

AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

— Fábio Konder Comparato

153

COMERCIALIZAÇÃO DE CIGARROS, INCONSTITUCIONALIDADE DA RESTRIÇÃO AO NÚMERO DE UNIDADES — INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO, LIVRE INICIATIVA E PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

— Eros Roberto Grau

160

PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

— Maria Sylvia Zanella Di Pietro

168

ver a Resolução 1/89; e c) substituir as comissões mistas singulares por uma Comissão Permanente para apreciação das medidas provisórias.

Não é preciso mencionar as medidas clássicas de defesa da cidadania contra governos ilegítimos e suas práticas. O descumprimento da norma ilegal é dever de todo cidadão, sua inaplicação, dever de todo juiz. A alternativa, aqui, é entre obedecer-se ao

Executivo ou aplicar-se a Constituição. Enganou-se, em seu relatório, o constituinte Egrégio Ferreira Lima; não há na história formal da democracia de decreto-lei, nem aqui, nem no exterior, e qualquer eventual vantagem decorrente de sua disponibilidade é largamente superada pelas inúmeras desvantagens de seu uso, principalmente em países de tradição autoritária.

Santos, agosto de 1999

DOCTRINA

CONCEITO DE INTERESSE PÚBLICO E A "PERSONALIZAÇÃO" DO DIREITO ADMINISTRATIVO

MARÇAL JUSTEN FILHO

Doutor em Direito

1. Regime de Direito Público e interesse público

Antes da afirmação do constitucionalismo, o núcleo da atividade administrativa do Estado se reputava pouco permeável ao Direito e ao controle jurisdicional. Os atos do governante não comportavam controle, sob o postulado de que o rei não podia errar ou que o conteúdo do Direito se identificava com a vontade do príncipe.

Essa situação não se alterou radicalmente mesmo após a consagração do conceito de Estado de Direito. Ao longo deste século XX, temas fundamentais do Direito Administrativo foram o poder de *imperium* estatal, a discricionariedade (elevada à noção de *Poder*) e os *atos políticos*. Havia uma defasagem entre garantias e limites constitucionais ao exercício do poder político e o desempenho da atividade administrativa do Estado. Em suma, os postulados do Direito Administrativo, nos temas de maior relevância, conduziam à impossibilidade de controle da atuação do governante. Essa situação apenas se modificou nas últimas décadas, com a permanente ampliação dos instrumentos de controle da atividade administrativa. Pode afirmar-se que o percurso do Direito Administrativo tem testemunhado a

lenta e inevitável transição do autoritarismo para a democracia. Atualmente, não mais se admite a idéia de "*ato discricionário*", reconhecendo-se que apenas alguns aspectos do ato administrativo envolvem margem de liberdade de escolha para o agente público. Os controles à atividade administrativa do Estado são cada vez mais intensos. Reconheceu-se que toda liberdade atribuída ao agente estatal tem de ser exercitada de modo compatível com os princípios jurídicos fundamentais. Isso não elimina uma espécie de força inerencial dos postulados do passado, afetando a compreensão e aplicação do Direito Administrativo do presente.¹

Nesse contexto, o conceito de *interesse público* tem desempenhado função relevante. Afirmar sua supremacia corresponde a reconhecer natureza instrumental aos poderes titularizados pelo Estado e agentes públicos. O exercício das competências públicas se orienta necessariamente à realização do referido interesse público.² Isso signifi-

1. Esse fenômeno foi apontado, com muito maior autoridade, por Agustín Gordillo (*Tratado de Derecho Administrativo*, Buenos Aires, Fund. de Derecho Administrativo, 1997, 4ª ed., t. I, pp. II-1/30).

2. Acerca da relevância dos princípios da indisponibilidade e da supremacia do interesse pú-

ca que a interpretação de todas as normas atributivas de poder funda-se em diretriz hermenêutica fundamental, afetando todas as relações jurídicas contidas no âmbito do Direito Administrativo. A construção doutrinária que privilegia o interesse público apresenta uma evolução marcante em direção à democratização do poder político.

Existe, no entanto, forte cunho de indeterminação no conceito de *interesse público*, o que dá margem ao risco de sua aplicação desaturada. No passado, invocava-se o poder de império, o poder discricionário, o poder de polícia ou a natureza política do ato. Hoje, ninguém ousaria respaldar ato abusivo em tais argumentos. Mas são comuns os casos em que o exercente do poder político refugia-se no princípio da supremacia do interesse público. É necessário prosseguir na tentativa de determinar o conceito de *interesse público*, em face do risco da aplicação equivocada do referido princípio.

2. O conceito de "interesse público"

Toda obra de Direito Administrativo alude a *interesse público*, mas sem definir a expressão nem apresentar um conceito mais preciso. O discurso restringe-se a afirmar a relevância do *interesse público* para a construção dos institutos do Direito Administrativo. Bem por isso, Tercio Sampaio Ferraz

público e do regime de Direito Administrativo, confira-se Celso Antônio Bandeira de Mello, *Curso de Direito Administrativo*, Malheiros Editores, 1999, 11ª ed., pp. 29 e ss. Nunca se olvide, ademais, o papel precursor do ilustre administrativista também nesse setor, ao submeter a abordagem do instituto da autarquia ao modelo de análise fundado na idéia de regime de *Direito Público*. Quanto a isso, confira-se a excepcional obra *Natureza e Regime Jurídico das Autarquias* (Ed. RT, 1968), especialmente às pp. 168-170 e 236-247.

3. Algumas considerações sobre o tema, já foram expostas em trabalho anterior, publicado sob o título "O princípio da moralidade pública e o Direito Tributário", *RDIT* 67/65-79, Malheiros Editores, s/d.

Júnior observou que *interesse público* é um lugar comum e que, justamente por isso, dispensa definição precisa, o que permite utilização mais eficiente.⁴

Tem de reconhecer-se que não é simples definir *interesse público*, inclusive por sua natureza de conceito jurídico indeterminado. Lembre-se que a função desempenhada pelos conceitos indeterminados exige uma abertura permanente em face da realidade. A indeterminação não é um defeito do conceito, mas um atributo destinado a permitir sua aplicação mais adequada a um caso. A indeterminação dos limites do conceito propicia a aproximação do sistema normativo à riqueza do mundo real.⁵

Isso não impede aprofundar o núcleo do conceito indeterminado, o que propicia maior precisão (e utilidade) em sua aplicação. Aliás, um exame mais minucioso do tema evidencia que o conceito de *interesse público* vem sendo alterado ao longo do tempo, em face da evolução histórico-cultural dos regimes democráticos.

2.1 Interesse público e interesse do Estado

A tradição jurídica costuma identificar *interesse público* e *interesse do Estado*. Há uma espécie de circularidade: o interesse é público porque atribuído ao Estado e é atribuído ao Estado porque público. Na época do surgimento do Estado moderno, em torno do séc. XVI, não seria exagerado afirmar que a totalidade dos interesses públicos estava na titularidade do Estado. Aliás, confundia-se interesse público e interesse

do soberano. Nesse cenário, era inviável distinguir um núcleo conceitual que desse identidade a *interesse público*.

Com o desenvolvimento político e social, há tendência a reconhecer a possibilidade de interesses públicos não estatais, especialmente no segmento das atividades de ordem não governamentais (ONGs). No entanto, permaneceu a concepção de que to-ganizações não governamentais pelo Estado são dos os interesses titularizados pelo Estado. Essas asserções exigem exame crítico.

O conceito de *interesse público* não se constrói a partir da identidade do seu titular, sob pena de inversão lógica e axiológica insuperável e frustração da sua função. Definir o interesse como público porque titularizado pelo Estado significa assumir uma certa escala de valores. Deixa de indagar-se acerca do conteúdo do interesse para dar-se destaque à titularidade estatal. Isso corresponde à concepção de que o Estado é mais importante do que a comunidade e que detém interesses peculiares. O tratamento jurídico do interesse público não seria consequência de alguma peculiaridade verificável quanto ao próprio interesse, mas da supremacia estatal. Como o Estado é instrumento de realização dos interesses públicos, tem de reconhecer-se que o conceito de interesse público é anterior ao conceito de interesse do Estado.

Por outro lado, não teria maior utilidade reconhecer o princípio da supremacia do interesse público quando adotada a concepção da qualidade do titular do interesse. Em última análise, poderia aludir-se a um princípio da supremacia do Estado — o que conduziria à impossibilidade de utilizar o princípio como instrumento de controle do exercício do poder político.

Logo, o interesse é público não por atribuído ao Estado, mas é atribuído ao Estado por ser público.

Isso significa admitir a existência de interesses privados de titularidade do Estado? A pergunta está mal formulada. Parte do pressuposto de que um interesse qual-quer, de natureza privada, poderia ser atribuído ao Estado, dando origem à dúvida: o interesse privado atribuído ao Estado continuaria a ser privado ou passaria a ser público? A pergunta é despropositada porque nenhum interesse exclusivamente privado possui interesse exclusivo do Estado. Em um Estado Democrático de Direito, o Estado somente está legitimado a ser sujeito de interesse público. Atribuir ao Estado a titularidade de interesse privado seria infringir o princípio da República. Justamente por isso, deve reconhecer-se que o conceito de interesse público é anterior (lógica e axiologicamente) ao conceito de Estado.

Isso não elimina a possibilidade de que, concretamente, o Estado se invista na titularidade de interesses privados. Tal ocorreu na história recente do Brasil. Por exemplo, durante o período não democrático, houve confisco de bens privados e foram integrados ao patrimônio da União bens e empreendimentos particulares. O Estado passou a ser titular de empresas que não envolviam qualquer espécie de interesse público, mantendo-as em seu poder e dando continuidade à atividade empresarial. Observe-se que tal situação poderia, em tese, verificar-se mesmo no âmbito de um regime democrático. A idêntico resultado poderia chegar-se através do instituto da herança vacante (Código Civil brasileiro, arts. 1.593 e 1.594) ou de alguma liberalidade de particular (doação etc.). A única solução jurídica em situações dessa ordem reside em o Estado imediatamente promover a reintegração dos bens e direitos no âmbito privado. Verificando que se tornou, circunstancialmente, titular de interesse privado, o Estado não tem outra alternativa. Deverá transferir os bens para a esfera dos particulares, gratuita ou onerosamente. Será teratológico e infringente à ordem constitucional que o Estado dê seguimento, por si mesmo, à realização dos interesses privados.

Observe-se que a natureza do interesse não determina o regime jurídico a ser adotado. Tanto é verdade que se admite atividade estatal sujeita ao Direito Privado. Isso se

passa com frequência no âmbito da Administração indireta não autárquica. Até a própria Administração direta está subordinada ao regime privado, em determinadas situações. Por exemplo, aplicar-se-ão as regras privadas acerca do contrato de seguro quando o segurado for pessoa de Direito Público.⁶ Em todas as hipóteses, no entanto, a Administração Pública estará perseguindo a realização do interesse público.

Em síntese, a titularidade pelo Estado representa, quando muito, um indicio de ser público o interesse, mas esse indicio conduz, como não poderia deixar de ser, a uma presunção relativa.

2.2 Interesse público e interesse do aparato administrativo

O interesse público não consiste no *interesse do aparato estatal*. O Estado, como sujeito de direito, pode adquirir certas *conveniências*, em termos equivalentes ao que se passa com qualquer sujeito privado. Não significa, porém, que tais circunstâncias se caracterizem como *interesses públicos*, para os fins da aplicação dos princípios ora examinados. Configura-se a distinção apontada por Renato Alessi entre *interesse público primário* e *interesse secundário*, difundida no Brasil por Celso Antônio Bandeira de Mello.⁷ Enfim, como afirmou Gordillo,

6. Isso não significa, porém, que a atividade específica do ente estatal seja disciplinada pelo Direito Privado. Assim, a prática do ato jurídico será subordinada às regras de Direito Administrativo.

7. Como ensina C. A. Bandeira de Mello, o Estado "Poderia, portanto, ter o interesse secundário de resistir ao pagamento de indenizações, ainda que procedentes, ou de denegar pretensões bem fundadas que os administrados lhe fizessem, ou de cobrar tributos ou tarifas por valores exagerados. Estaria, por tal modo, defendendo interesses apenas 'seus', enquanto pessoa, enquanto entidade animada do propósito de despendêr o mínimo de recursos e abarrotar-se deles ao máximo. Não estaria, entretanto, atendendo ao interesse público, ao

"o interesse público não é o interesse da Administração Pública".⁸ É impertinso ter em vista que nenhum *interesse público* se configura como *conveniência egoística da Administração Pública*. O chamado *interesse secundário* (Alessi) ou *interesse da Administração Pública* não é público. Ousa-se afirmar que nem ao menos são *interesses*, na acepção jurídica do termo. São meras *conveniências* circunstanciais, alheias ao Direito. O Estado não possui *interesses* qualitativamente similares aos *interesses* dos particulares, pois não foi instituído para buscar satisfacões similares às que norteiam a vida dos particulares. A tentativa de obter a maior vantagem possível é válida e lícita, observados os limites do Direito, apenas para os sujeitos privados. Não é admissível para o Estado, que somente está legitimado a atuar para realizar o bem comum e a satisfação geral. O Estado não pode ludibriar, espolar ou prevalecer-se da fraqueza ou da ignorância alheia. Aliás, nem um particular poderia atuar desse modo, muito menos o Estado. O interesse público não reside em obter lucro, se tal se fizer através de atividades especulativas, de duvidosa valia ética.

Podem ser lembradas certas hipóteses peculiares, em que o Estado toma a si o desenvolvimento de empresas moralmente reprováveis. Assim se passa com atividade de loterias, no Brasil. Em outros países, é usual o monopólio da exploração do fumo. Conhecem-se hipóteses em que o próprio Estado fornece drogas a viciados, visando a minorar certas situações maléficas. Deve ter-se em vista que, ao assumir tais tarefas, o Estado não atua de modo similar aos particulares. Não se trata de obter lucros ou incentivar a realização de valores negativos.

interesse primário, isto é, àquele que a lei aponta como sendo o interesse da coletividade: o da ob-servância da ordem jurídica estabelecida a título de bem comum e do interesse de todos" (*Curso de Direito Administrativo*, cit., p. 30).

8. *Tratado de Direito Administrativo*, cit., p. 2, p. XIII-17.

A iniciativa estatal, em tais campos, deriva da constatação de que a solução mais adequada é liberar a prática de certas atividades (ainda que moralmente inaceitáveis), quando a impossibilidade de obter sua eliminação no âmbito social. Em outros casos, o Estado assume seu desempenho para evitar males ainda maiores e tentar impedir a disseminação da criminalidade ou de doenças. Supõe-se, em última análise, que o Estado poderá manter sob controle o desenvolvimento de empreendimentos reprováveis. Esse controle derivará precisamente da correção ética a que se sujeita a atuação estatal. Outra questão a discutir é se tais propósitos têm sido bem sucedidos, tema que extrapola os limites deste trabalho.

2.3 Interesse público e interesse privado da pessoa física do agente público

É imprescindível distinguir e afastar, também, o interesse privado do sujeito que exerce função pública. O exercício da função pública não pode ser afetado pelos interesses privados e egoísticos do agente público. Eles continuam a ser interesses privados, submetidos às regras comuns, que disciplinam a generalidade dos integrantes da comunidade. Assim, por exemplo, os direitos de propriedade privada de que um sujeito seja titular não se subordinam, de regra, a uma alteração de regime jurídico se dito sujeito passar à condição de agente público. Logo, não se poderia cogitar de um regime especial e diverso, por exemplo, para tributação sobre bens de agentes públicos.

O tema relaciona-se com a questão do interesse privado do sujeito como exercente da função pública. Por exemplo, o governante pode ter interesse em evitar divulgação de notícias que possam prejudicar sua manutenção no cargo eletivo. Mas esse é um interesse privado e particular dele, inconfundível com o interesse público. Somente se poderia cogitar da aplicação do regime de Direito público na medida em que estivesse em jogo o interesse público, tal como se daria quando houvesse risco à dignidade de cargo ou função.

2.4 Interesse público propriamente dito

O processo histórico-evolutivo conduziu à superação de qualquer identificação entre interesse público e as meras conveniências do Estado ou dos agentes públicos. O conceito ganhou autonomia, o que não significa que o pensamento jurídico tenha atingido concepções unânimes. Existem, pelo menos, quatro vertentes de abordagem da questão.

2.4.1 Interesse público como somatório dos interesses privados

A primeira proposta para definir interesse público é relacionada a uma espécie de generalização indutiva dos interesses privados. Em face dessa teoria, o interesse público se configuraria a partir do interesse privado. Consideram-se os interesses dos particulares e se produz uma modalidade de *avaliação aritmética*. Nesse enfoque, o interesse público corresponde ao interesse comum e homogêneo da totalidade ou da maior parte do povo. Segundo essa abordagem, não há diferença *qualitativa* entre interesse privado e público. A diferença é de natureza *quantitativa*. Afinal, todo e qualquer interesse privado poderá configurar-se como público desde que configurada uniformidade dos interesses da maioria.⁹

2.4.2 Interesse público como somatório de determinados interesses privados

Outra concepção, próxima à anterior, reconhece que nem todo interesse privado

9. Em certa medida, esse é o posicionamento de Héctor Jorge Escola, ao afirmar que "El interés público, entendido con el carácter y el sentido que lhe hemos asignado, no tiene una entidad ontoló-

poderia transformar-se em público. Haveria, quando menos, duas categorias de interesses privados. Existiriam interesses privados pertencentes à existência individual egoística, cuja conjugação nunca conduziria à configuração de um interesse público. Seriam interesses essencialmente individuais, nunca passíveis de transformar-se em públicos. Ao lado deles, haveria interesses privados transcendentes à individualidade e que poderiam dar origem a um interesse público, na medida em que ocorresse homogeneidade coletiva.

Essa teoria comporta duas variantes. Uma delas defende o pressuposto da maioria: somente há interesse público quando o interesse particular especial é de titularidade da maioria. Há outra concepção que entende possível que alguns interesses privados especiais sejam relevantes o suficiente para dispensar o requisito da maioria. Bastaria que parcelas significativas da sociedade apresentassem interesses comuns dessa ordem para o reconhecimento da publicidade do interesse.

2.4.3 Interesse público como interesse da sociedade

Entendimento diverso se caracteriza quando se afirma que público é o interesse da sociedade, entendida como algo indefinível com o mero somatório dos indivíduos. Considera-se que o todo (conjunto de indivíduos) é mais do que o produto da soma das unidades. De fato, em termos sociológicos, é inquestionável que a sociedade é um *sujeito* distinto, inconfundível com os indivi-

duos que nela se integram. Sob determinado ângulo, o interesse público seria o interesse da *instituição*¹⁰ social. A sociedade supera e transcende, no tempo e espaço, os indivíduos que a integram, inclusive na aceção de que a modificação individual não afeta a identidade do grupo. Os valores do passado, integrados como patrimônio cultural, permeiam a comunidade, moldando cada indivíduo. Os interesses individuais não são produzidos autonomamente por cada ser humano, mas são o resultado da conjugação da individualidade com o ambiente (social, inclusive) circundante.¹¹ Portanto, o interesse público pode desvincular-se dos interesses que, de modo concreto, algum particular detenha.

2.4.4 Considerações críticas às concepções tradicionais de interesse público

As construções acima sumariadas comportam inúmeras críticas. A primeira e mais relevante dirige-se contra um pressuposto adotado na abordagem. Qualquer que seja a teoria adotada acerca de *interesse público*, é impossível afirmar a configuração de uma situações simples e homogêneas. Uma das características do Estado contemporâneo é a fragmentação dos interesses, a afirmação conjunta de posições subjetivas contrapostas e a variação dos arranjos entre diferentes grupos. A temática relaciona-se com o fenômeno do acesso de uma pluralidade de "classes" ao poder e que produziu o surgimento do *Estado pluriclasse*. A consi-

10. Acerca do conceito de instituição, conferam-se as observações (inclusive com referência bibliográfica) constantes de minha obra *Desconstrução da Personalidade Societária no Direito Brasileiro*, Ed. RT, 1986, pp. 30 e ss.

11. Não seria fora de propósito lembrar Ortega y Gasset, quando afirmava o célebre "eu sou eu e minha circunstância" (*Meditaciones de Quince*, Livro Ibero-Americano, 1967, trad. da 2ª ed. espanhola, p. 52).

pressão, indicando composições temporárias e limitadas entre os diferentes segmentos da sociedade.

O próprio Giannini destaca a heterogeneidade dos interesses públicos em um panorama sócio-político dessa ordem.¹³ Antes do surgimento do Estado pluriclasse, era possível afirmar a contraposição entre interesse privado e interesse público. Após, tornou-se impossível reconhecer situação assim tão simples.

Nesse contexto, a utilização do conceito de interesse público tem de fazer-se com cautela, diante da pluralidade e contradição entre os interesses dos diferentes integrantes da sociedade.

Daí deriva, em primeiro lugar, a imprestabilidade da concepção que identifica *interesse público* com *interesse da maioria*. Não há como localizar uma maioria propriamente dita, com cunho de permanência. Nem existe um conjunto suficientemente homogêneo de interesses privados ao qual se pudesse atribuir a condição de *interesse da maioria*. Sempre haveria uma pluralidade de sujeitos, com interesses contrapostos e distintos. Portanto e como disse Casese, "não existe o interesse público, mas os interesses públicos, no plural".¹⁴

Nem seria o caso de considerar a maioria como titular de dois interesses simultaneamente. Um seria aquele contraposto ao da minoria. Mas, ao mesmo tempo, a maioria teria interesse em que a minoria fosse prestigiada. Logo, seria interesse público tanto o da maioria quanto o da minoria. Nesse caso, o interesse da minoria seria público não por alguma característica própria, mas por ser de titularidade da maioria. A construção é obviamente artificiosa e impossível de ser sustentada. Basta lembrar que, adotada tal concepção, desaparecerão os interesses privados: todos serão públicos.

12. Confira-se *Diritto Amministrativo*, Milano, Giuffrè, 1970, I, pp. 45-50. Consulte-se, ainda, a ampla retrospectiva elaborada por Sabino Cassese, "Lo stato pluriclasse in Massimo Severo Giannini", em *L'Unità del Diritto* — Massimo Severo Giannini e la Teoria Giuridica, Bolonha, Il Mulino, 1994, pp. 11-50.

13. *Diritto Amministrativo*, cit., p. 106.

14. *Le Basi del Diritto Amministrativo*, Torino, Einaudi, 1991, p. 238.

Na verdade, um Estado Democrático caracteriza-se não pela prevalência do interesse da maioria, considerada apenas em termos quantitativos. Consiste na supremacia da vontade da maioria eventual e *também* na garantia aos interesses da minoria, tudo segundo parâmetros constitucionalmente fixados.¹⁵ A idéia de interesse público não se prende a questões apenas quantitativas. Assim, por exemplo, existe interesse público em tutelar minorias raciais, ainda que os interesses delas possam eventualmente conflitar com os da maioria do povo.¹⁶

Enfim, não há dúvidas acerca da existência de interesses *coletivos* e *difusos* que, não obstante sua pertinência a uma pluralidade de sujeitos privados, continuam a ter natureza privada.¹⁷

Mas permanece um problema notável, que evidencia o equívoco da concepção aritmética de interesse público. Trata-se do reconhecimento do interesse da minoria como público. Adotar um critério quantitativo se revela insuficiente e inadequado, eis que interesse público não é sinônimo de interesse da maioria. Muitas vezes, as maiorias são titulares do interesse público. Outras vezes, porém, o interesse público coincide com o

15. Acerca da dinâmica entre interesse público e interesse privado, consulte-se o estudo de Juan Pablo Cajarville Peluffo, "Garantías constitucionales del procedimiento administrativo en los países del Mercosur: Principios del procedimiento administrativo de los órganos del Mercosur", revista *Actualidad en el Derecho Público*, Buenos Aires, Ad-Hoc, v. 8, 1998, pp. 32 e ss..

16. Contra essa concepção de interesse público como interesse da maioria dos indivíduos, confira-se, ainda, o texto de René Mario Coane, "Estado, bien común e interés público", transcrito em *El Derecho Administrativo Argentino, Hoy*, Buenos Aires, Editorial Ciencias de la Administración, 1996, pp. 36-48.

17. Sobre o tema, confira-se os ensinamentos de Carlos Manuel Grecco em "Ensayo preliminar sobre los denominados intereses 'difusos' o 'colectivos' y su protección judicial", em *Fragmentos y Testimonios del Derecho Administrativo*, Buenos Aires, Ad-Hoc, 1999, pp. 687-709.

da minoria. Ou seja, o interesse é qualificado como público não por razões meramente quantitativas. Existem interesses que não são gerais e continuam a ser públicos.

Isso não significa aceitar, sem maiores objeções, a concepção do *interesse da sociedade*. Essa construção produz duas dificuldades fundamentais. A primeira reside no risco de surgir um *interesse social* desvinculado de qualquer interesse individual concreto. Haveria uma espécie de cristalização social, em que a tradição superaria a dimensão da realidade concreta. A desvinculação entre a dimensão individual e o interesse público contém o germe do autoritarismo. É o primeiro passo para o reconhecimento de interesses supra-individuais, de configuração totalitária e cuja lamentável afirmação se verificou nos regimes do nacional-socialismo alemão e do estalinismo. A segunda refere-se à identificação do conteúdo do interesse. Já que não há compromisso com os interesses individuais concretos, surge o problema de determinar o interesse social. Seria necessário atribuir a algum sujeito o *power* de diagnosticar a existência e determinar o conteúdo do *interesse público*. Enfim, essa concepção de interesse público propicia construções políticas não democráticas, com elevado potencial de nocividade.

2.4.5 A natureza "técnica" das concepções tradicionais de interesse público

Por outro lado, essas abordagens comum enfrentadas podem ser qualificadas como *concepções técnicas de interesse público*. Partem do pressuposto de que alguns interesses privados não podem ser satisfeitos através da atuação isolada dos próprios particulares. A insuficiência dos esforços individuais exige a intervenção do Estado. Aliás, a própria existência do Estado seria justificada por essa via. A associação entre os seres humanos, produzindo a sociedade e o Estado, destina-se a propiciar a superação de dificuldades de maior dimensão. Assim,

o interesse público seria resultado da conjugação de dois elementos. Um seria a existência de interesses gerais e comuns e o outro, a insuficiência dos esforços individuais para a satisfação.¹⁸ Qualificam-se essas teorias como *técnicas* porque a consistência do interesse público reside na mera impossibilidade de sua satisfação através da atividade individual e isolada. A técnica para satisfação do interesse é a reunião dos seres humanos. Em última análise, a forma de atendimento ao interesse privado é sua transformação em público, o que permite que a sociedade, como organização de pessoas e recursos, enfrente e supere dificuldades supra-individuais.

Ocorre que a concepção técnica de interesse público vinculou-se a circunstâncias muito específicas, peculiares a determinadas situações históricas. Até as últimas décadas do séc. XX, a riqueza privada era insuficiente (na maioria dos países) para produzir a satisfação dos interesses coletivos. Era imprescindível a intervenção estatal e a utilização dos recursos públicos como instrumento para tanto. Mas a evolução sócio-econômica, verificada ao longo do séc. XX, tornou problemática a manutenção de concepções dessa ordem. Os processos econômicos de geração e acumulação de riqueza alteraram radicalmente esse panorama. A chamada *sociedade civil* tornou-se titular de meios materiais e de conhecimento técnico suficiente para produzir a satisfação dessas necessidades. Os recursos econômicos privados são suficientes para os investimentos em infra-estrutura indispensáveis ao atendimento dos interesses individuais. A tecnologia desenvolvida no âmbito da iniciativa privada é, em grande parte dos casos, mais eficiente e adequada do que a titularizada pelo Estado. Por outro lado, o Estado não dispõe de recursos disponíveis para realização de todas as tarefas de atendimento aos interesses coletivos.

Apesar de o ser humano isolado continuar incapacitado de enfrentar todas as necessidades privadas, isso não significa que a única via de satisfação dessas necessidades seja a estatal.¹⁹

Em suma, a solução *técnica* para satisfação dos interesses coletivos não é mais justificativa adequada para fundamentar o conceito de interesse público. Surgiram novas técnicas de satisfação de interesses gerais, mais eficientes do que aquelas tradicionalmente conhecidas. É possível manter os interesses como privados e, não obstante isso, produzir sua satisfação. Aliás, produzir-se-á sua satisfação com muito maior eficiência do que pelo caminho da *publicização* do interesse. Ao invés de considerar o interesse como público e afetá-lo ao Estado, aplicando-lhe regime jurídico distinto e peculiar, é perfeitamente viável dar solução às necessidades na órbita privada. Assim, os recursos privados podem ser aplicados para obras de grande envergadura, destinadas a atender os interesses gerais. Os *serviços públicos tradicionais* admitem exploração similar à prestação de qualquer utilidade privada.²⁰

2.4.6 Síntese: a natureza "ética" da questão

Nesse ponto, é necessária uma radical modificação no panorama jurídico. O conceito de interesse público não comporta en-

19. Tem de destacar-se que esse panorama foi influenciado diretamente pela experiência norte-americana, em que a maioria dos interesses individuais sempre foram atendidos segundo modelo de mercado. Com a expansão econômica e o fenômeno da globalização, todos os países passaram a ser confrontados com essa alternativa.

20. Sobre o tratamento do tema na Comunidade Europeia, confira-se as lições de Sabino Cassese em "De la vieja a la nueva disciplina en los servicios públicos", revista *Actualidad en el Derecho Público*, Buenos Aires, Ad-Hoc, v. 8, 1998, pp. 19-24.

18. Nessa linha, confira-se o entendimento de Jean Riviéro e Jean Waline, *Droit Administratif*, Paris, Dalloz, 1998, 17ª ed., pp. 12-13.

foque meramente técnico. A transmutação do interesse de privado em público não deriva de um imperativo meramente técnico, mas de imposições éticas. É verdade que existem necessidades privadas que não podem ser satisfeitas pelo esforço individual e isolado de cada qual. Também procede o raciocínio de que a sociedade civil e as organizações econômicas privadas dispõem de recursos satisfatórios para atendimento a essas necessidades. Ocorre que tais demandas são diretamente relacionadas à realização de princípios e valores fundamentais, especialmente a dignidade da pessoa humana. O interesse deixa de ser privado porque sua satisfação não pode ser objeto de alguma transigência. É impossível admitir que se apliquem à satisfação dessas necessidades as regras jurídicas que disciplinam o atendimento aos demais interesses individuais, sob pena de admitir possibilidade de sua não realização. Ora, a ausência de satisfação a eles significaria infringir os valores fundamentais consagrados pelo ordenamento jurídico.

Considere-se uma situação prática, envolvendo o interesse em obter energia elétrica. Supõe-se inviável que as necessidades individuais de consumo de energia elétrica sejam satisfeitas através do esforço de cada ser humano, isoladamente. Em um primeiro momento histórico, poderia imaginar-se que apenas o Estado disporia de recursos para produzir a satisfação a esses interesses. Logo, estaria em jogo um interesse público. Mas, nos dias atuais, é inquestionável que inúmeras empresas privadas dispõem de condições de assumir a satisfação desse interesse. Por isso, é necessário definir-se a atividade de fornecimento de energia elétrica corresponde à satisfação de interesse público ou de interesse privado. Optar pelo interesse privado significa subordinar o fornecimento da energia elétrica às regras de mercado. Nesse caso, deverá admitir-se que a necessidade de algumas pessoas não será atendida. Aqueles que não dispuserem de recursos suficientes para adquirir os produ-

tos e serviços estarão aliçados do mercado. A energia elétrica passará a ser um produto no mercado, do mesmo modo que outros bens de consumo. Há pessoas que dispõem de recursos para adquirir televisores, outros não. Tal como alguns não têm televisores, outros não terão energia elétrica. Ora, a energia elétrica não se assemelha àquela penitente a outros bens de consumo. A energia elétrica é indispensável à obtenção de certas utilidades indissociáveis da realização plena da personalidade humana. A penitência econômica não legitima o impedimento à satisfação do interesse individual relacionado à satisfação da dignidade da pessoa humana.

Modernamente, o conceito de interesse público não se constrói a partir da impossibilidade técnica de os particulares satisfazerem determinados interesses individuais, mas pela afirmação da impossibilidade ética de deixar de atendê-los. Até se pode admitir que o Estado restrinja sua atuação na satisfação do interesse público. Mas a dessatização não significa a despublicização. A utilização de técnicas mais eficientes não autoriza a transformação do público em privado. O conceito de interesse público é permeado por caracteres éticos dessa ordem.

As considerações acima demonstram a ausência de natureza unitária do conceito de interesse público. Não é apenas um interesse social, mas necessariamente também um interesse individual concretamente compartilhado por segmentos significativos da sociedade. Somente se evidencia um interesse público quando há compatibilidade entre o interesse social e o interesse titularizado por uma pluralidade de sujeitos integrantes da comunidade, em um dado momento. Não é necessário, por isso, que o interesse público seja o interesse da maioria eventual, em certa situação. O que se exige é a compatibilidade entre o interesse grupal e o interesse de uma parcela da população. Sob esse ângulo, poderia utilizar-se a expressão *interesse coletivo*.

Ainda assim, essa fórmula não se afigura suficiente para determinar o que é interesse público. É extremamente precária e pouco operacional, como se evidencia facilmente. Basta uma pergunta concreta para comprovar a insuficiência do conceito. Suponha-se a seguinte indagação: a pena de morte atende ao interesse público? É impossível responder a essa pergunta utilizando-se apenas os dados conceituais acima delineados. A expressão *interesse público*, considerada sob um ângulo puramente técnico, é tão imprecisa que pode conduzir a decisões opostas e antagônicas.

3. O princípio da dignidade da pessoa humana

Em um Estado de Direito, caracteriza-se pelo princípio da República, vigoram pressupostos e limites inafastáveis para o exercício do poder político, atingindo a atuação das pessoas investidas formalmente na condição de órgãos estatais. O princípio da República reconhece à comunidade a titularidade de todo poder, que é exercido pelo povo, diretamente ou através de seus representantes (CF/88, art. 1º, parágrafo único). Afigura-se, porém, que o regime de Direito Administrativo e o exercício do poder político apenas adquirem sentido completo e perfeito quando relacionados ao princípio máximo da supremacia da dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1º, III).

A dignidade da pessoa humana é o princípio fundamental, de que todos os demais princípios derivam e que norteia todas as regras jurídicas.²¹ Mesmo a supremacia e indisponibilidade do interesse público são subordinados a ele. Mais precisamente, sua preminência e indisponibilidade do interesse público são a via insubstituível para realiza-

ção da dignidade da pessoa humana, que consiste na concepção de que o ser humano não é instrumento, em qualquer das acepções que a palavra apresente. O ser humano não pode ser tratado como objeto. É o sujeito de toda a relação social e nunca pode ser sacrificado em homenagem a alguma necessidade circunstancial ou, mesmo, a propósito da realização de fins últimos de outros seres humanos ou de uma *coletividade* indeterminada. O fim primeiro e último do poder político é o ser humano, ente supremo, sobre todas as circunstâncias. Não há valor que possa equiparar-se ou sobrepor-se à pessoa humana, que é reconhecida como integridade, abrangendo quer os aspectos físicos como também seus aspectos imateriais. A dignidade relaciona-se com a *integridade* do ser humano, na acepção de um todo insusceptível de redução, em qualquer de seus aspectos fundamentais.

A supremacia da dignidade da pessoa humana acarreta a equiparação de todos os seres humanos. Cada um e todos merecem idêntico respeito. Não se admite que alguns tenham "dignidade" maior do que outros. A isonomia inviabiliza diferenciações transcendentais: todos os seres humanos, em origem, são iguais. Por isso, ninguém pode ter sua dignidade sacrificada em benefício alheio.

Mas a dignidade da pessoa humana não poderia realizar-se plenamente se as relações intersubjetivas fossem deixadas ao sabor dos esforços individuais, desorganizados. Independentemente de enfrentar a discussão acerca da natureza política do ser humano, assume-se a existência de organizações intersubjetivas como via relevante de sobrevivência. Essas organizações consistem em meio de conjugar os esforços individuais e disciplinar o exercício da força. Abrangem o Estado e as instituições jurídicas. Sua estruturação e funcionamento têm de ser disciplinadas pelo princípio da dignidade da pessoa humana.²² A existência do

21. Não é possível olvidar a importância que, nesse tema, apresenta a Lei Fundamental da Alemanha de 1949, cujo art. 1º, n. 1, estabeleceu: "A dignidade da pessoa humana é sagrada. Todos os agentes da autoridade pública têm o dever absoluto de a respeitar e proteger".

22. Como afirma Benda, "(...) o postulado do Estado social (...) veda uma interpretação pura-

. Estado apenas se justifica em face do aludido do princípio.

3.1 Transcendentalidade do princípio da dignidade da pessoa humana

O princípio da dignidade da pessoa humana desempenha em relação ao Direito e ao Estado uma função que se poderia dizer *transcendental*. Não equivale, apenas, a afirmar que ocupa posição de superioridade quanto aos demais princípios e valores — o que significaria sua transcendência em relação aos demais. Não é apenas transcendente; ele é transcendental.²³ Sua transcendentalidade significa condição apriorística de possibilidade de existência e compreensão do sistema jurídico. Ou seja, todo o sistema jurídico desenvolve-se a partir do princípio da dignidade da pessoa humana e somente adquire sentido e se torna compreensível em virtude dele. Ele não apenas está acima dos demais princípios, mas está *antes* deles. A antecedência é referida não no sentido cronológico, mas lógico.²⁴

mente individualista das normas fundamentais e evita o equívoco consistente em abandonar sua referência e vinculação à comunidade em aras da dignidade do indivíduo (...). O Direito Constitucional não pode eximir o legislador da tarefa de alcançar uma solução justa que dissipe a tensão entre a liberdade do indivíduo e os pressupostos do Estado social" (Benda, Mahofet, Vogel, Heyde, *Manual de Derecho Constitucional*, Madrid, Instituto Vasco de Administración Pública, Marcial Pons, 1996, p. 120, orig. em castelhano).

23. A diferença entre *transcendência* e *transcendentalidade* é bastante simples, em termos filosóficos, especialmente após Kant. Transcendência significa uma espécie de superioridade; transcendentalidade indica precedência lógica ou exame das condições para que algo possa existir. Na palavra de Kant, "Chamo *transcendental* a todo o conhecimento que em geral se ocupa menos dos objectos, que do nosso modo de os conhecer, na medida em que este deve ser possível *a priori*" (*Crítica da Razão Pura*, Lisboa, Calouste Gulbenkian, 1994, 3ª ed., p. 53).

24. Sob um certo ângulo, poder-se-ia estabelecer algum paralelo entre o princípio da digni-

3.2 Princípio da dignidade da pessoa humana e jusunaturalismo

Essas construções poderiam ser tomadas como uma profissão de fé jusunaturalista. De fato, há alguma comunhão com o pensamento jusunaturalista, mas as diferenças são notáveis.

As concepções jusunaturalistas tendem a ser não-históricas. O jusunaturalismo relaciona-se usualmente com o reconhecimentalismo de postulados superiores ou alheios à existência humana. Isso conduz a uma espécie de duplicação do Direito, distinguindo-se aquele produzido pela sociedade histórica e um modelo abstrato ou ideal, válidos independentemente de considerações temporais ou espaciais.²⁵

A concepção ora defendida é diversa. Afirma-se que a dignidade da pessoa humana é um valor *constituído* ao longo da história humana. A vivência dos seres humanos, desde momentos primitivos até o atual estágio, produziu a consagração do valor da dignidade da pessoa humana como princípio fundamental. Essa é uma concepção histórico-evolutiva dos valores.²⁶ Portanto, aceita que a dignidade da pessoa humana não foi o valor fundamental desde os primórdios da história do ser humano. Como valor transcendental, foi uma conquista do séc. XX,

dade da pessoa humana e a norma fundamental referida por Kelsen. Mas a distinção entre os conceitos é clara. A norma fundamental de Kelsen não tem propriamente um conteúdo material, devendo ser tomada como um pressuposto lógico de possibilidade. Já o princípio da dignidade da pessoa humana apresenta um conteúdo material e axiológico, que dá "sentido", antes do que fundamento lógico, ao ordenamento.

25. Sobre o tema, consulte-se Juan Carlos Cassagne, *De Nuevo sobre los Principios Generales del Derecho en el Derecho Administrativo Argentino*, Hoy, cit., pp. 24 e ss.

26. Sobre o tema, consulte-se Miguel Reale, *Filosofia do Direito*, Saraiva, 1983, 10ª ed., pp. 208 e ss.

ção. Esses princípios fundamentais estão indicados na Constituição, ainda que seu conteúdo possa ser determinado em função das variações dinâmicas da vida social. Logo e ainda que se consagre uma constituição aberta, isso não significa que o intérprete esteja autorizado a recorrer à sua própria consciência individual como critério de reconhecimento do Direito Positivo.²⁹

3.3 Dignidade da pessoa humana e Direito Público

O exercício das funções estatais apenas pode legitimar-se como instrumento de realização e tutela da dignidade da pessoa humana. Nessa linha, a fórmula da *supremacia do interesse público* tem de ser compreendida em sua inteireza e pensada com cautela. Até mesmo pela força do tempo e da tradição, há o risco de ser interpretada como "prevalência do *imperium* estatal".

Não se pode admitir que a *supremacia do interesse público* seja aplicada como algo bastante em si mesmo. Afirmar que a realização do interesse público é o princípio supremo do ordenamento jurídico é extremamente perigoso. Esse postulado pode conduzir à instauração de regimes totalitários, à destruição da democracia e ao sacrifício de valores inerentes à integridade do indivíduo. Abre-se oportunidade para o sacrifício dos demais valores, resolvendo-se o conflito entre *interesse público* e *interesse privado* pela destruição do último. Essa não é uma concepção admissível em face do Direito, eis que o interesse público não é o valor de mais alta hierarquia. Na escala dos valores, o de maior dimensão é o da dignidade da pessoa humana.³⁰ Como afirma Canotilho, "a Repu-

27. A expressão foi cunhada por Hannah Arendt, *The Origins of Totalitarianism*, San Diego, Nova York-Londres, Harcourt Brace Company, nova edição, s.d., pp. 460 e ss.

28. *Povo* não se confunde com *Nação*. Confira-se a obra de Friedrich Müller, *Quem é o Povo?*, Max Limonad, 1998, especialmente às pp. 52-53.

29. Sobre o tema, consulte-se Canotilho, *Di-
reito Constitucional e Teoria da Constituição*,
Coimbra, Almedina, 1998, pp. 81 e ss.

30. Em sentido similar e com abordagens inovadoras, Juárez Feltes já se havia manifestado com precedência. Afirmava, então, ser necessário respeitar "as considerações acerca do transcendental prin-

blica é uma organização política que serve o homem, não é o homem que serve os aparelhos político-organizacionais".³¹

Apenas pode atribuir-se relevância ao *interesse público* quando imediatamente submisso ao princípio da dignidade da pessoa humana. Em nenhum momento, pode sacrificar-se a dignidade de um único particular a pretexto de realizá-lo,³² pois não há interesse público que autorize o desmerecimento da dignidade de um sujeito privado.

4. "Personalização" do Direito Administrativo

É oportuno produzir uma revisão de pressupostos e formas de abordagem do Direito Administrativo. Atingiu-se a patamar de consciência jurídica que permite adoção de novos programas e propostas para a atividade administrativa do Estado. Não seria equivocado aludir à necessidade de *personalização do Direito Administrativo*.

4.1 Os movimentos no âmbito do Direito Civil

A expressão *personalização* se reporta a posicionamentos emergentes no âmbito do Direito Civil contemporâneo. Inúmeros doutrinadores têm defendido uma revisão dos seus pressupostos axiológicos, ideológicos e temáticos. Refutam a concepção que privilegia o *patrimônio* como núcleo de organização do Direito Civil. Afirmam que o ser humano é ponto nuclear em torno do qual surgem relações jurídicas privadas. O

cípio da universalização do interesse público e da correlata subordinação das ações estatais à dignidade da pessoa humana" (*O Controle dos Atos Administrativos e os Princípios Fundamentais*, Malheiros Editores, 1997, p. 52).

31. *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*, cit., p. 219.

32. Pode-se dizer que, ao fazer isso, desvirtua-se o interesse público, confundindo-o com o interesse estatal. Sobre esse assunto, confira-se o ponto 4.2, adiante.

valor da dignidade da pessoa humana antecede a todas as concepções patrimonialistas. A tutela ao patrimônio é uma das vias de afirmação da dignidade da pessoa humana, mas não a única (nem, talvez, a mais relevante).³³ Pretendem, por isso, a *repersonalização* do Direito Civil, para restabelecer a preponderância dos valores relacionados ao ser humano e a suas virtudes essenciais.

Algo similar deve ponderar-se a propósito do Direito Administrativo. Os fundamentos desse ramo do Direito têm merecido uma espécie de autonomia axiológica. Os poderes e competências estatais não são considerados como instrumentos e assumem a condição de fins em si mesmos. Para ser mais preciso, tais poderes e competências são tratados como instrumentos de realização do *interesse público*. No entanto, esquece-se ser o *interesse público* uma manifestação da dignidade da pessoa humana. Somente se compreende interesse público como um valor acessório. *Interesse público* não é um valor compreensível ou bastante em si mesmo. Aí reside o ponto de ruptura, eis que o único fim em si mesmo é a pessoa humana.

4.2 A "personalização" do Direito Administrativo

Não é possível aludir a *repersonalização* do Direito Administrativo, que *nunca* assumiu como valor fundamental o ser hu-

33. "Esta despatrimonialização do direito civil não significa a exclusão do conteúdo patrimonial no direito, mas a funcionalização do próprio sistema econômico, diversificando sua valoração qualitativa, no sentido de direcioná-lo para produzir respeitando a dignidade da pessoa humana (e o meio ambiente) e distribuir as riquezas com maior justiça" (Carmen Lucia Silveira Ramos, "A maior justiça" (Carmen Lucia Silveira Ramos e a sociedade constitucionalização do direito privado e a sociedade sem fronteiras", na obra conjunta *Repensando os Fundamentos do Direito Civil Brasileiro Contemporâneo*, Renovar, 1998, p. 17). Entre os autores das novas idéias, devem destacar-se Luiz Edson Fachin e Gustavo Tepedino.

mano, o indivíduo ou a dignidade da pessoa humana. Ao menos, concepções nesse sentido jamais foram acompanhadas de algum efeito concreto ou prático. O Direito Administrativo sempre foi considerado um conjunto de regras *contra* o particular, *contra* o Estado e *sobre* os agentes públicos. Afinal e como já visto, o próprio conceito de interesse público foi construído no âmbito do autoritarismo político, o que produziu sequelas marcantes.

A personalização do Direito Administrativo propicia reconhecer que a Administração Pública não apresenta valores intrínsecos. Também aqui a direttriz primeira é a dignidade da pessoa humana. A atividade administrativa do Estado tem de nortear-se pela realização desse valor, inclusive (e especialmente) quando se trata de interesses de minorias e dos destituídos de poder. Não se admite que os titulares do poder político legitimem decisões invocando a *conveniência* do interesse público e produzam, concretamente, o sacrifício do valor fundamental. O núcleo do Direito Administrativo não é o *poder* (e suas conveniências), mas a realização do interesse público — entendido como afirmação da supremacia da dignidade da pessoa humana.

Essa postura não retrata alguma proposta individualista. Ao menos, não se trata de defender a supremacia do indivíduo em face da coletividade. Reconhece-se a integridade individual, mas de *todos* os indivíduos. O interesse da maioria é digno de maior proteção do que o interesse de uma quantidade menor de particulares. O que não se admite é diluição da dignidade de um único indivíduo em virtude da existência de um incerto e indefinido *interesse público*.

A personalização do Direito Administrativo retrata a rejeição à supremacia da burocracia sobre a sociedade civil. Volta-se a combater o fenômeno usual: a propósito de identificar o *interesse público*, o agente público conveniências ao aparato administrativo. Desvincula-se do compromisso com a reali-

zação dos interesses da comunidade. Isso é inadmissível, eis que a atividade administrativa tem de legitimar-se como via de realização dos interesses privados — na acepção de que o interesse público é produto da sua conjugação.

Mas também há uma perspectiva de rejeição da subordinação dos organismos estatais aos interesses de determinados grupos. Nenhuma minoria pode ser oprimida, mas também não pode transformar-se em opressora. Quando se alude a minoria, tomam-se em vista os diferentes critérios de organização, inclusive o econômico. O Direito é instrumento compensatório das desigualdades entre as pessoas e os grupos. Assegura-se a dignidade da pessoa humana na medida em que se cumpre essa função. Vale dizer, o poder econômico de certos grupos ou particulares tem de ser limitado através do Direito, inclusive através da atividade da Administração Pública e da regulação produzida pelas normas administrativas.

Como se verá adiante, a personalização do Direito Administrativo envolve a superação de concepções meramente técnicas para assumir a prevalência de enfoque ético, em que se assume a supremacia de certos valores e princípios.

4.3 Interesse público e satisfação dos valores fundamentais

É necessário adicionar aos dados fornecidos outro aspecto do conceito de interesse público. Trata-se da realização dos valores jurídicos fundamentais. O interesse público se pertaça com a satisfação de necessidades de segmentos da população, em um momento concreto, para realizar os valores fundamentais. O interesse público é o interesse da sociedade e da população, mas voltado à realização dos valores de mais elevada hierarquia.

Nesse ponto, torna-se extremamente útil a tese da *personalização do Direito Administrativo*. Se o valor fundamental é a dig-

tidade da pessoa humana, então interesse público não pode ser compreendido senão como a demanda de realização desse valor. Os poderes atribuídos ao Estado, no âmbito da função administrativa, não são voltados a produzir um *interesse público* abstrato, difuso ou apenas cognoscível por parte do governante. A atividade administrativa do Estado se orienta a atender as necessidades individuais e coletivas pertinentes ao valor da dignidade da pessoa humana.

Atribui-se ao Estado (preponderantemente) a função de realizar o interesse público precisamente pela relevância da dignidade da pessoa humana. Não poderia deixar-se a satisfação desse valor fundamental ao sabor da iniciativa particular e individual. Dota-se o Estado de um arsenal de poderes jurídicos cuja dimensão é compatível com a relevância do valor a realizar.

Essa concepção de interesse público permite responder às perguntas concretas. Assim e por exemplo, deve-se afirmar que, como a pena de morte não realiza o princípio da dignidade da pessoa humana, sua adoção é incompatível com o interesse público. A personalização do Direito Administrativo dá conteúdo próprio ao princípio da supremacia do interesse público e torna-o operacional do ponto de vista da concretização dos valores jurídicos fundamentais. Ainda que a expressão *interesse público* permaneça como um *topos*, um conceito jurídico indeterminado, a personalização produz circunscrição semântica de fundamental relevância.

Nenhum governante pode legitimar suas decisões através da pura e simples invocação ao *interesse público*. Será necessário, sempre, demonstrar como os efeitos concretos da decisão conduzirão à realização do princípio da dignidade da pessoa humana, segundo o espírito do ordenamento jurídico.

Até se poderia reconduzir a essa concepção um enfoque de Ronald Dworkin, acerca de democracia. Diante do problema de identificar o conceito de *governo da*

maioria, Dworkin reconhece que a finalidade da democracia não consiste em adotar decisões coletivas coincidentes com a vontade da maioria dos cidadãos. O fim buscado pela democracia é outro: "que as decisões coletivas sejam adotadas por instituições políticas cuja estrutura, composição e prática, enquanto indivíduos, com identidade, cupação e respeito".³⁴ Adaptando essas considerações ao enfoque ora defendido, pode dizer-se que o texto acima orienta-se na mesma linha. A dignidade da pessoa humana impõe o tratamento equitativo de todos em sociedade, exigindo estruturas políticas que assegurem e realizem essa igualdade.

4.4 Interesse público e harmonização entre interesses distintos

O postulado da supremacia da dignidade da pessoa humana propicia superação de inúmeros *obstáculos aritméticos* relacionados com a identificação do interesse público. Pode afirmar-se, em termos gerais, que o interesse público envolve a prevalência dos valores relacionados ao ser humano como sujeito central de todos os processos intersubjetivos. Mas isso não basta para eliminar o problema da heterogeneidade dos interesses.

Existe questão complexa, relativa à existência de inúmeros centros de interesses contrapostos. Poderia afirmar-se, em termos preliminares, que não se configuraria como interesse público qualquer necessidade ou demanda social incompatível ou contraditória com a realização dos valores da pessoa humana. Ainda que realizassem primeira depuração, as dúvidas não estariam afastadas. Em alguns casos, existiriam interesses igualmente relacionados ao princípio da dignidade da pessoa humana, todos eles contraditórios entre si. Em ou-

tras situações, não seria possível determinar a pertinência de algum interesse em face do aludido princípio. Alguns exemplos, ainda que não imediatamente relacionados com o Direito Administrativo, facilitam a compreensão do problema.

Suponha-se o problema da fixação da carga tributária. Há o interesse de elevação da arrecadação estatal, o que propiciará recursos para melhor pagamento dos funcionários públicos e prestação mais adequada de serviços estatais. Mas também há o interesse na preservação do patrimônio particular, visando à ampliação das atividades econômicas privadas. Em ambos os casos, poderia afirmar-se um *interesse público*. É tanto do interesse público ampliar a carga fiscal como reduzi-la.

Por outro lado, imagine-se a determinação da via de direção do tráfego em uma via pública. Estabelecer-se os veículos trafegará em direção ao norte ou ao sul dependendo da aplicação do interesse público. Mas é problemático vincular alguma das alternativas à realização imediata e concreta da supremacia da dignidade da pessoa humana.

Essas dificuldades não importam obstáculos intransponíveis nem devem conduzir ao ceticismo acerca da prevalência dos princípios fundamentais.

4.4.1 Dignidade da pessoa humana e soluções fundadas na técnica

Afigura-se mais simples o problema da impossibilidade de identificar vínculo entre o princípio da prevalência dos interesses humanos e os diferentes interesses em jogo.

Afirmar a natureza ética do interesse público não significa afastar considerações técnicas. Ambos os temas se relacionam, eis que a ética não exclui a adoção da melhor solução do ponto de vista técnico. O que a ética exclui é que as decisões sejam adotadas desvinculadas a realização dos valores relacionados com a dignidade. Ou seja, o enfo-

que ora defendido não envolve alguma modalidade de obscurantismo anti-científico.

A supremacia da dignidade da pessoa humana significa que nenhum interesse poderá ser considerado como *público* se produzir o sacrifício dos valores fundamentais. Mas, respeitados esses valores, é evidente que a solução terá de respeitar a técnica, a ciência e o conhecimento. Quando for impossível determinar qualquer infração à supremacia da pessoa humana, estar-se-á no campo próprio da decisão técnico-científica. Mais precisamente, a preponderância da quele princípio exige que todos os recursos públicos sejam utilizados com a maior eficiência possível. Desse modo, será mais provável a satisfação dos diferentes interesses privados e públicos. Portanto, a supremacia da pessoa humana exige não apenas o respeito direto ao ser humano e a seus valores, mas também a utilização mais racional e eficiente de todos os recursos públicos.

Sob esse ângulo, o tema se relaciona com o próprio conceito de discricionariedade. O Direito reconhece margens de liberdade de decisão aos agentes públicos, precisamente para propiciar a adoção da melhor escolha no caso concreto. Em grande parte dos casos, a melhor escolha não é produzida por juízos subjetivos mas deriva de informações e critérios formulados segundo as leis científicas e o conhecimento técnico.

Por isso, pode afirmar-se que o interesse público coincide com a adoção de certa orientação para o trânsito quando houver critério técnico para fundar uma escolha. Lembre-se, por exemplo, que certas vias de trânsito são modificadas conforme o horário do dia, para fazer frente às demandas quantitativas de veículos. A alternância das regras de trânsito corresponde ao interesse público se tal for imposto pela técnica.

Se nenhuma solução for a mais aconselhável em face do conhecimento técnico-científico, estar-se-á diante do campo mais próprio da discricionariedade. Não será possível afirmar previamente que a solução adotada corresponderá à satisfação do interes-

34. *Freedom's Law*, Cambridge, Harvard University Press, 1996, p. 17, orig. em inglês.

se público. Mais precisamente, todas as soluções comportadas em face da ética e da técnica serão equivalentes e realizarão, de modo equivalente, o interesse público. Esse conceito funcionará muito mais como critério negativo do que positivo: serão inválidas as decisões que contrariarem o interesse público, entendido no caso como as soluções comportadas em face do conhecimento técnico-científico e dos princípios jurídicos fundamentais. Incumbirá ao agente público realizar a escolha dentro do universo das soluções possíveis.

4.4.2 Superação dos conflitos entre interesses contrapostos

Mais difícil é determinar a solução quando presentes interesses diferentes e contrapostos, todos os quais relacionáveis à supremacia da dignidade da pessoa humana. Não se afigura cabível afirmar que essa situação legitimaria a escolha de qualquer um dos interesses, impondo-se o sacrifício aleatório de algum deles.

A problemática pode ser relacionada com uma conhecida construção de Dworkin acerca da pluralidade de soluções para os litígios, *vexata quaestio* para a Filosofia do Direito. O autor americano sustentou a possibilidade de sempre encontrar-se uma única solução para o caso concreto. Em última análise, a temática de Dworkin é a mesma ora considerada a propósito do interesse público. Defendendo a concepção do Direito como integridade, afirma que a tarefa de aplicar a lei envolve a verificação da solução mais coerente com os princípios jurídicos consagrados.³⁵ O aplicador do Direito deve inserir-se no processo mais amplo de produção jurídica, segundo uma perspectiva de continuidade que não se confunde com o puro tradicionalismo. Sempre será possí-

vel reconhecer uma certa decisão como sendo a *mais* compatível com os princípios jurídicos fundamentais então vigentes.

O tema evidencia-se diretamente relacionado ao princípio da razoabilidade, na vertente da proporcionalidade.³⁶ Há necessidade de *ponderação* dos interesses e dos valores a que se relacionam. Quando os diferentes interesses em arito comportam equivalente tutela e proteção, a solução adequada é propiciar a realização mais — ainda que limitada — de todos eles. A solução mais adequada em face do Ordenamento é produzir a *homogeneização* dos diferentes interesses. Introduzem-se limitações e reduções nos diferentes interesses, de molde a compatibilizá-los. Ainda que um interesse seja evidentemente mais relevante do que os demais, não se autoriza sua realização absoluta, se tal acarretar o sacrifício integral de interesses que comportam proteção do Direito. Tem de buscar-se, sempre, a solução que realize mais intensamente todos os interesses, inclusive na aceção de não produzir a destruição de valores de menor hierarquia.

Essa atividade de uniformização dos interesses envolve exercício do poder político, inclusive com manifestações de discricionariedade. Subordina-se à observância dos princípios jurídicos fundamentais mas também à observância do *devido processo legal*. A autoridade estatal não pode impor certa solução, afirmando ser a que traduz o interesse público, sem observar os princípios procedimentais e processuais cabíveis. Especialmente quando se considerar um Estado pluriclasse, é imprescindível dar oportunidade de manifestação a todos os grupos

de interesse. A adequação da decisão final resulta da observância das etapas procedimentais, com garantia de contraditório e segundo uma atuação imparcial.

4.5 Impossibilidade da definição "a priori" do interesse público

A determinação do conteúdo do interesse público produz-se ao longo do processo de produção e aplicação do Direito. Não se de produção público prévio ao Direito, se há interesse público abstrata insuficiente como manifestação de uma solução definida. O processo de concretização do Direito produz a seleção dos interesses, com a identificação do que se reputará como interesse público em face das circunstâncias. Não há qualquer caráter predeterminado (como, por exemplo, a qualidade do titular) apto a qualificar o interesse como público. Essa peculiaridade não pode ser reputada como negativa. Aliás, muito ao contrário, representa a superação de soluções formalistas, inadéquadas a propiciar a realização dos valores fundamentais acatados pela comunidade. O processo de democratização conduz à necessidade de verificar, em cada oportunidade, como se configura o interesse público. Sempre e em todos os casos, tal se dá através da intangibilidade dos valores relacionados à dignidade do ser humano.

5. A "filosofia" do sistema e os princípios e regras

Deve referir-se, enfim, a uma *filosofia* do sistema político-jurídico, consistente na consagração da supremacia da dignidade da pessoa humana.

A expressão *filosofia* indica não apenas a prevalência dos princípios fundamentais, mas a consagração de uma organização acerca deles. Sob um certo ângulo, indicando que se poderia denominar de *arquitectura dos princípios*. Ou seja, não basta afirmar a preponderância de determinados prin-

cípios, pois é relevante também o modo como são eles organizados, a ênfase que se atribui a cada qual e os fins últimos que se buscam realizar.

Ao defender a personalização do Direito Administrativo, pretende-se consagrar a natureza instrumental de todos os demais princípios em face da dignidade da pessoa humana. Assume-se uma *filosofia* para o Direito com profundas implicações. Todos os princípios e regras devem ser interpretados e aplicados como meio para realização daquele princípio supremo. Pode-se (e deve-se) sacrificar um princípio menor quando tal se faça necessário para evitar ofensa à *filosofia* do sistema.

Nesse contexto, não se pode admitir que a *filosofia* ou *espírito* do Direito Administrativo consista em afirmar a superioridade da Administração Pública em face do administrador. A Administração Pública não "vale" mais do que um particular. Aliás, até se poderia reconhecer que "vale" menos, pois apenas se legitima como instrumento de realização dos interesses públicos. Já o particular se legitima como fim em si mesmo. Nem se pode asseverar, pura e simplesmente, que o interesse público é superior e prepondera sobre o interesse privado.

Adotar uma *filosofia* para o sistema permite superar certas dificuldades, especialmente quando se enfrentam conflitos entre princípios juridicamente tutelados. Supor uma *harmonia* interna e automática entre os diferentes interesses não corresponde a qualquer verdade. Os conflitos são permanentes e continuados. É possível obter a superação das contradições por inúmeras vias jurídicas, as quais produzem um sacrifício mais ou menos limitado de todos os interesses contrapostos. Ou seja, afirma-se que a compreensão do ordenamento jurídico não envolve apenas a ponderação dos valores e princípios. A organização faz-se segundo um vetor fundamental, o que permite identificar a *filosofia* ou *espírito* do sistema.

Não se trata de afirmar que essa construção se identifique com algum fundamento

35. Confira-se *Taking Rights Seriously*, Cambridge, Harvard University Press, 1977, pp. 81 e ss., e *Law's Empire*, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press, 1995, 9ª ed., *passim*.

36. A bibliografia acerca do tema é bastante rica. No Brasil, há duas obras específicas acerca da questão. Trata-se dos livros de Raquel Denzê Stumm, *Princípio da Proporcionalidade no Direito Constitucional Brasileiro*, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 1995, e Suzana de Toledo Barrios, *O Princípio da Proporcionalidade e o Controle de Constitucionalidade das Leis Restritivas de Direitos Fundamentais*, Brasília Jurídica, 1996.

último, nos moldes do pensamento kelseniano. É claro que, diferentemente das concepções de feição kelseniana, a presente formulação se relaciona com uma questão axiológica. Ainda que todos os valores se entrelacem e se impliquem mútua e reciprocamente, há um critério de organização dos valores. O que se defende é que os valores jurídicos se organizam e adquirem sentido a partir da supremacia do princípio da dignidade da pessoa humana, que norteia todo o processo hermenêutico.

A distinção fica muito clara quando se comparam sistemas jurídicos com *filosofias* distintas. Suponha-se um sistema em que a filosofia seja a preponderância do princípio da eficiência e compare-se-o com outro, em que o espírito seja construído a partir do princípio da dignidade da pessoa humana. Imagine-se que os dois sistemas jurídicos se materializem em cartas constitucionais quase idênticas — nada impede que tal ocorra. Textos constitucionais equivalentes e princípios jurídicos similares serão compreendidos de modo totalmente distinto. Em um caso, o exercício do poder e a regulação da conduta intersubjetiva norteiam-se-á pelo postulado da eficiência pragmática. Já no outro, o fim a ser atingido é permeado por valorações éticas, em que a técnica despenha meras funções instrumentais.

6. Relevância da distinção entre interesse público e interesse privado

Há o risco de que exame dessa ordem conduza à negativa da distinção entre interesse público e privado. Até mesmo na esteira da proposta de superação da dicotomia "Direito Público/Direito Privado", poder-se-ia supor que o conceito de interesse público seria secundário. Afinal, se a compreensão do conceito de interesse público apenas pode fazer-se à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, alguém diria que bastaria este último para a existência do ordenamento jurídico. Essa, porém, é uma posição equivocada.

É verdade que a compreensão do conceito de interesse público faz-se à luz do valor da dignidade da pessoa humana. Isso não significa esvaziar o conceito de interesse público. Aliás, dá-se precisamente o contrário. Reconhece-se a existência de interesses (individuais ou coletivos) de relevância tamanha que sua proteção não pode ser atribuída exclusivamente ao indivíduo. São interesses cuja realização é imperiosa. É tão inafastável a realização desses interesses que se afasta o postulado da liberdade. Não é possível admitir que o interesse seja ou não realizado, segundo a vontade dos particulares, que podem escolher entre satisfazer ou não certos interesses. Essa liberdade apenas vigora quando esses interesses não sejam relacionados diretamente com o princípio da dignidade da pessoa humana.

Com isso, não se afirma que dignidade da pessoa humana seja um valor incompatível com os interesses privados. Pode-se afirmar que os interesses privados têm de ser exercitados em função do referido princípio, mas a eventual ausência de satisfação do interesse não importa sua necessária frustração. O interesse passa a ser público quando sua frustração acarreta inevitável ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Portanto, os interesses privados podem deixar de ser realizados e satisfetos se isso não produzir desmerecimento à dignidade da pessoa humana.

Poder-se-ia dizer que todo interesse, uma vez relacionado à dignidade da pessoa humana, qualifica-se como *público*? Sob um certo ângulo, a resposta é positiva. Não é por outro motivo que características típicas do interesse público aplicam-se aos direitos personalíssimos. O que se pode afirmar é que a vinculação entre o interesse e a realização do princípio da dignidade da pessoa humana impede a aplicação das regras peculiares do Direito Privado. São esses os fundamentos pelos quais se nega natureza privativa a grande quantidade de regras do Direito do Trabalho e de Direito do Consumidor.

Isso não quer dizer que se defenda que o interesse público seria sempre de titularidade direta e exclusiva dos particulares e não do Estado. Reconhece-se que o Estado não é o único titular dos interesses públicos. Além disso e tal como exposto acima, não se confundem interesse público e interesse estatal. Também se admite a existência de interesses públicos não estatais, que podem ser de titularidade dos particulares, individualmente ou como coletividade. Podem ser perseguidos pelos próprios indivíduos ou por organizações não governamentais. Nesse caso, ainda que sejam defendidos por particulares, continuam a ser interesses públicos. No entanto, isso não conduz a negar-se a titularidade pelo Estado de vários interesses públicos. Defender o vínculo indissociável entre interesse público e dignidade da pessoa humana não significa afirmar a ausência de interesses titularizados privativamente pelo Estado, especialmente no tocante às situações políticas.

7. Interesse público e valores políticos

Nessa linha, poder-se-ia questionar se o princípio da dignidade da pessoa humana estaria presente também no âmbito da política, que envolve questões atinentes à existência do Estado e ao funcionamento das instituições públicas. Afinal, a própria CF/88 alude a *soberania e cidadania*, nos incs. I e II do art. 1º.

Deve-se considerar que todos esses valores fundamentais se entrelaçam e conjugam. No entanto, a compreensão de todos os valores *políticos* faz-se em função do princípio da supremacia da dignidade da pessoa humana. A soberania é atributo de autonomia política do Estado-Nação, cuja afirmação é instrumento de assegurar a plena realização da dignidade do ser humano. A supressão da soberania impede a realização daquele princípio, na medida em que subordina a condução da vida social e indivi-

dual a decisões adotadas por outros povos, pessoas ou grupos.

O mesmo se diga quanto à democracia, a república, a livre iniciativa, a garantia de trabalho, valores cuja realização somente adquire sentido em face do princípio da dignidade da pessoa humana. Não se compreende a relevância inafastável da democracia enquanto se a considera *apenas* como uma técnica de organização do exercício do poder, caracterizada pela livre participação de todos e cada um na vida política. Essa participação conjunta é meio indispensável para realizar um governo orientado à dignidade da pessoa humana. A excelência da democracia não reside em virtudes técnicas organizacionais. Aliás, alguém poderia sustentar que, sob o ponto de vista da ciência das organizações, a democracia não seria a solução dotada de maior eficiência. Mas a questão não pode ser resolvida por critérios meramente de técnica ou eficiência organizacional. Seja ou não a democracia a fórmula mais adequada de gestão dos interesses públicos, sua afirmação e consagração decorre de outros postulados. A virtude da democracia reside em assegurar a impossibilidade da prevalência permanente de interesses uniformes de determinados setores ou classes sociais na vida política. A organização política pluriclasse propicia a afirmação concomitante (ainda que irracional) dos interesses de diferentes classes e grupos. Isso é essencial para tutelar a dignidade de todos os indivíduos, seja porque impede a ditadura de certos grupos, seja porque o interesse de cada segmento realiza-se ao menos parcialmente.

Essas ponderações podem ser realizadas em face dos demais princípios e valores políticos.

Em última análise, rejeita-se a possibilidade de invocação a qualquer fórmula *relacionada ao espírito do povo, à salvaguarda nacional* e outras similares, em que a dignidade da pessoa humana é sacrificada para realizar o pretenso interesse do grupo.

Essas considerações produzem efeitos significativos na análise dos diferentes institutos do Direito Administrativo, todos permeados pela idéia de um regime jurídico próprio. Poderia fazer-se referência aos conceitos de discricionariedade e às limitações produzidas por via do dito *poder de polícia*. Mas parece que especial relevo merece o exame das competências estatais quanto a atendimento a necessidades individuais. A discussão sobre *serviço público* e a adoção de modelos de livre competição deve orientar-se pela superioridade do princípio da dignidade da pessoa humana.

O tema central da chamada *reforma do Estado* refere-se aos encargos reservados ao Estado e a submissão de certas atividades de interesse coletivo ao regime de Direito Público. Alguns defendem a redução radical da dimensão do Estado, invocando a necessidade de alocação racional de recursos públicos. Outros defendem posição oposta. Todos os diferentes segmentos de opinião pretendem afirmar a supremacia do interesse público, o que deriva da ausência de definição do que se entende por *interesse público* no caso concreto.

Nesse contexto, é imprescindível adotar enfoque compatível com a *personalidade* do Direito. É necessário evitar que a prevalência do chamado *princípio da eficiência* faça-se às custas do aviltamento do indivíduo. Equivale a dizer que a solução da crise fiscal do Estado não pode fazer-se pela *patrimonialização* do Direito Público. É necessário evitar a prevalência do chamado *princípio da eficiência* às custas do aviltamento da dignidade da pessoa humana. A configuração de um Estado Democrático de Direito depende de que a atividade da Administração Pública seja norteada pela concepção de que todos os seres humanos merecem idêntico respeito. Alguns têm de receber especial atenção por parte do Estado. São precisamente aqueles cuja dignidade não pode ser protegida ou realizada por seus próprios esforços e com seus recursos individuais isolados. Mas seria um enorme equívoco e um trágico erro político imaginar que a extinção do Estado poderia ocorrer simultaneamente à preservação da dignidade individual da minoria governante. A supremacia da dignidade da pessoa humana constitui-se não apenas em um imperativo sob o ponto de vista filosófico. Trata-se de um ensinamento adquirido à custa de enormes sacrificios e sofrimentos infindáveis ao longo da História.

DOCTRINA

REEDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA (Visão Comparativa das Jurisprudências da Corte Constitucional Italiana e do STF)

EDILSON PEREIRA NOBRE JÚNIOR

Juiz Federal — Professor do Curso de Direito da UFRN
e da ESMARN — Mestre pela UFPE

No escopo de examinar-se a possibilidade ou não de reedição da medida provisória, teria dos mais caros a aguçar as mediações dos juristas, merecem atenção especiais dois pontos. O primeiro deles se situa em eventual óbice no art. 67 da CF, ao dispor que a matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá ser alvo de nova proposição, na mesma sessão legislativa,¹ mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional.

Na doutrina proliferam controvérsias. Raul Machado Horta² vislumbra não existir óbice sob a ótica do art. 67 da Lei Máxima, cuja vedação se dirige unicamente aos projetos de lei rejeitados. Contudo, afirma que dois fundamentos desaconselham a re-

novação da medida provisória quando expressamente recusada, ora por projetar a aparência de conflito político entre o Presidente da República e o Parlamento, ora em virtude da própria Constituição haver oferecido a solução a ser adotada, impondo ao Congresso Nacional a obrigação de disciplinar as relações jurídicas decorrentes das medidas não convertidas em lei. Quanto ao transcurso do trinitário sem deliberação congressual conclusiva, pende pela admissibilidade da reapresentação contanto que o Legislativo, em juízo de prelibação, conclua pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência.

A esse pensamento não fora infenso Saulo Ramos³ que, a par de sustentar a impossibilidade de incidência do art. 67 da Lei Maior, somente concebe a reedição mediante duas condições: a) não tenha ocorrido a rejeição expressa da medida anterior; b) ainda subsistam as razões justificadoras de sua emanção (relevância e urgência).

Sem aludir se a espécie se encaixa ou não no art. 67 da CF, Manoel Gonçalves

1. Não esquecer que o limite temporal, relativo à mesma sessão legislativa, não equivale ao ano de dezembro, descrito no art. 57, caput, da CF, tendo na ADIn 1.441-DF (Pleno, rel. Min. Octávio Galbetti, *Informativo STF* 38).

2. "Medidas provisórias", *Revista de Informação Legislativa* 27(107):5-18, Brasília, jul.-set. 1990, p. 15.

3. Consultoria-Geral da República. Parecer SR 92, 21.6.89, *DOU* de 23.6.89, p. 10.185.